

1500456-57.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal. 2.

Recurso improvido'. (RHC 20.714/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 4/8/08).

E é evidente que o acusado estava em situação de plena flagrância, já que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500456-57.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500456-57.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032231/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 22814195 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 173/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2032231 - 03º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE, 173/22/925 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA, com dados qualificativos a fls. 24, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta de 21h40, na Avenida Ruth Garrido Roque, n.º 1190, no bairro Parque do Lago, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, na forma de crack, com cerca de 12,0 gramas; 199 (cento e

noventa e nove) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por “maconha”, com cerca de 284,0 gramas; e, 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, com cerca de 42,0 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação preliminar de fls. 15/16), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descrita acima, para entrega a consumo de terceiros no endereço acima referido, já conhecido ponto de venda de drogas.

Ocorreu que, na data dos fatos, guardas municipais realizavam patrulhamento pelo Bairro Parque do Lago quando avistaram o indiciado em atitude suspeita, pois empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura.

Em seguida, VITOR HENRIQUE foi perseguido e abordado pelos guardas municipais.

Realizada a revista pessoal, em poder do indiciado, os agentes localizaram no bolso da bermuda a quantia de R\$ 103,00 em notas diversas. Já no interior da pochete que ele portava foram encontradas as drogas acima descritas embaladas individualmente e prontas para a venda.

Questionado pelos guardas municipais, o indiciado confessou informalmente o delito, afirmando que estava comercializando entorpecentes há uma semana, que seu turno de trabalho era das 21h00 às 06h00 e que recebia em média R\$ 150,00 por dia trabalhado.

Interrogado pela D. Autoridade Policial, o indicado optou por permanecer em silêncio (fls. 09).

Portanto, a grande quantidade de drogas apreendidas, a variedade, a forma de acondicionamento, o encontro de dinheiro, bem como o relato dos agentes públicos dando conta da confissão informal do acusado, denotam claramente que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do indiciado se destinavam ao tráfico, que era por ele exercido.

O acusado foi notificado (fls. 178) e apresentou defesa preliminar (fls. 147/150). A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 (fls. 183/184) e o réu foi citado (fls. 202). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum e uma testemunha de defesa, e interrogado o acusado ao final.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e materialidade delitiva, bem assim o aumento da pena base em razão da natureza do entorpecente, e a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena. A defesa pugnou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, ilegalidade na ação dos guardas municipais, requereu a absolvição por falta de provas, ou, em caso de condenação, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, regime mais brando e substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Fundamento e decido.

De início, afasto a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da diligência solicitada às fls. 213/214.

Nos termos do artigo 400, §1º do Código de Processo Penal, é facultado ao Juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. In casu, não demonstrou a defesa a imprescindibilidade desta prova, sequer justificou o que pretende demonstrar com tais imagens. Supondo que a defesa queira apontar

eventuais ilegalidades na ação da guarda municipal, poderia fazê-lo com testemunhas do fato, arrolando não só os familiares citados pelo acusado em seu interrogatório, como também os funcionários do prédio, inclusive o tal síndico citado nas fls. 213/214, o que não ocorreu.

Não se justifica a providência do Juízo para oficiar a um determinado local requisitando imagens sem a certeza da existência material deste documento. Há mera hipótese levantada pela defesa da existência de tais imagens, e conforme já dito alhures, os mesmos fatos poderiam ser demonstrados com testemunhas, daí porque esta prova é totalmente prescindível.

Nesse sentido, cito julgado do E. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. [...] NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese em apreço, verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de produção da prova pretendida, circunstância que afasta a alegada ilegalidade. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019).

Assim, tratando-se de prova impertinente, fica indeferido o pedido, até mesmo para resguardar a celeridade processual, uma vez que se trata de réu preso.

Rejeito, também, a preliminar de nulidade processual, pois com relação à ação dos guardas municipais, cumpre assinalar que o art. 144, §8º da CF estabelece que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei" e que o art. 301 do CPP prevê que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

Assim, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais, constituiu ato legal, em proteção à segurança social, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento do E. STJ:

"RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSAO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no 8º, do art. 144, da Constituição Federal tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de auto defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processos Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 6.368/76 - modalidade guardar substância

entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 9/11/98).

Ademais, se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. A esse respeito, confira-se:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal. 2. Recurso improvido'. (RHC 20.714/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 4/8/08).

E é evidente que o acusado estava em situação de plena flagrância, já que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo ato de comércio ou venda, basta ter em depósito ou estar guardando, o que é o caso dos autos. E estando em situação de flagrância, qualquer um do povo poderia prendê-lo, o que se estende aos guardas municipais, restando ausente, portanto, qualquer nulidade na ação destes agentes.

Passo, então, a análise do mérito.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreendem do Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 15/16, laudo pericial de fls. 196/198, que constatou que as substâncias apreendidas tratam-se de cocaína, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Gilvan José dos Reis e Ailton Sandrin deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro, e no condomínio Manacá, que é conhecido como local de venda de drogas, avistaram o acusado. Ele correu quando avistou a viatura, e diante desta atitude, foi perseguido e abordado, ainda dentro do condomínio, mas próximo de uma área. Que em seu bolso havia R\$ 103,00, e na cintura havia uma pochete presa, contendo 67 porções de cocaína, 49 porções de crack e 199 porções de maconha. Que ele foi indagado e confessou de pronto a venda de drogas. Que seu turno era das 21 horas às 06 horas, e que por dia recebia R\$ 150,00. Que o acusado não era conhecido dos meios policiais. Ele foi abordado numa área verde. Que não sabem ao certo se há câmeras de vigilância no local, e se elas estão em funcionamento.

O acusado, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que foi ao local comprar uma porção de maconha, pois é usuário, e assim que pediu a droga para o traficante, a viatura da guarda municipal se aproximou. Que todos correram, e correu também, por medo, e foi abordado. Que havia apenas dinheiro com ele, R\$ 160,00, fruto do seu trabalho. Que os guardas acharam a pochete na mata. Eles foram para sua casa depois, e nada localizaram. Que fazia uns dois minutos que estava no condomínio. Mora em outro condomínio, chamado Cerejeira, e antes de ir para lá estava em casa com a genitora. Que tem 18 anos, é usuário de maconha, e nunca foi preso nem processado, nem teve passagens na Vara da Infância e Juventude. Trabalhava numa empresa chamada Ober, em Nova Odessa, das 07 às 17 horas. Começou a trabalhar dia 01 de dezembro. Não conhece os guardas municipais e pensa que há câmeras de vigilância no local.

Diante do conjunto probatório dos autos, tenho como certa a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, pois os relatos dos guardas municipais restaram suficientes para convencer o Juízo a respeito da autoria delitiva.

A versão trazida a Juízo, em que o réu busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime de tráfico, encontra-se em total divergência com todas as demais provas coletadas, o que torna a alegação desprovida de elementos que a consubstancie, eis que a quantidade de droga apreendida e de espécies variadas, em via pública, não se coaduna com a conduta de mero usuário.

De se esclarecer que o acusado, quando abordado pelos guardas municipais, confessou que estava vendendo drogas, e não há porque duvidar das alegações destes agentes, pois não se verificou, em nenhum momento, eventual desavença entre eles ou mesmo a intenção destes agentes em prejudicar uma pessoa inocente. E os depoimentos foram firmes, uníssonos e imparciais, e são aptos a ensejar um decreto condenatório, pois nada indica que mentiram em Juízo, ao contrário do acusado, que tem intenção de apresentar versão exculpatória para livrar-se de uma condenação, ainda que esta seja totalmente inverossímil.

Ademais, os depoimentos destes agentes se mostraram harmônicos e seguros, demonstrando idoneidade, razão pela qual confiro plena credibilidade para firmar meu convencimento.

E a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância do depoimento dos guardas municipais, quanto mais se não existe nenhum elemento nos autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

“PROVA. Depoimento policial. Valor. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal Recurso improvido neste aspecto” (Apelação Criminal n.993.08.043553-7, São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal Relator: Newton Neves 09.09.08 V.U. Voto n. 5652).

“PROVA. Depoimento de policial. Validade. Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado. Eficiência. Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva. Ocorrência - Apelação provida parcialmente” (Apelação

Criminal n. 1.002.701-3/7 São Paulo 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal
Relator: René Nunes 28.02.07 M.V. Voto n. 10.200).

Ademais, é notório que para a configuração do tráfico de drogas não há necessidade da prova da sua venda ou cessão, bastando que o entorpecente seja encontrado com a acusada para se atingir tal escopo.

No mais, alegando a condição de usuário, tinha a ré o ônus de comprovar as alegações, nos exatos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal: "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", mas disso não se desincumbiu, pois nenhuma prova veio aos autos que atestasse a sua condição de usuário das drogas, no caso, a maconha.

Nesse sentido:

"TÓXICO - Tráfico - Porte de "tijolinho" de maconha - Quantidade suficiente à confecção de oitenta cigarros - Ônus da demonstração de uso próprio pertencente à defesa - Presunção de destinação comercial - Admissibilidade - Recurso parcialmente provido para outro fim. O agente que, na via pública, traz consigo "tijolinho" de maconha, do qual se pode confeccionar cerca de oitenta cigarros, justifica a presunção de tráfico, sendo inadmissível o acolhimento da alegação de uso próprio sem prova cabal e irrefutável nesse sentido, ônus então da defesa". (Relator: Luiz Pantaleão - Apelação Criminal n. 139.646-3 - Araçatuba - 28.06.93).

"TRÁFICO - Tóxico - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimento dos policiais - Credibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 6.368/76 - Inadmissibilidade - Finalidade comercial evidenciada nos autos - Diversidade (maconha e cocaína), quantidade e forma de acondicionamento que respaldam a tipificação - Crime de natureza permanente que caracteriza-se com o simples fato de trazer consigo a droga - Ausência, ademais, de prova da exclusividade de uso próprio - Ônus da defesa - Sentença confirmada - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 290.772-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal "JANEIRO/2000" - Relator: Debatin Cardoso - 20.01.00 - V.U.).

Nem mesmo há prova de que o acusado estava outro local antes de ser abordado. Diz ele que estava com a mãe antes de ser abordado, em casa, e que saiu por poucos minutos para comprar a droga. Mas ninguém foi trazido em Juízo para corroborar tal versão, nem de que é usuário da maconha, nem que estava em outro local antes da abordagem, daí porque sua narrativa é totalmente isolada e não será acolhida pelo Juízo.

E o só fato do acusado ser usuário de drogas não a impede de ser traficante, aliás, tal tipo de comportamento é comum.

Tem-se, pois, que a quantidade e forma de acondicionamento dos tóxicos, além das circunstâncias da abordagem, não permitem a descCLASSIFICAÇÃO para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, restando o quadro probatório firme e robusto, de modo de não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico pelo acusado.

Assim, à vista dos elementos probatórios carreados aos autos confrontados com o interrogatório da ré, só resta reconhecer a responsabilidade deste pelo delito de tráfico, impondo-se sua condenação.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e de bons antecedentes. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do

produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, o réu comercializava quantidade elevada de crack e cocaína, o que vem em seu desfavor, diante da natureza nefasta do entorpecente, com grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. A conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.343/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima: “Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787). Nesse mesmo sentido, têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Por tais razões, aumento a pena base de 1/3, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e 583 dias-multa. Segunda fase: não há circunstância agravante, porém presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mantenho a pena em seu patamar mínimo, tendo vista a vedação de maior redução conforme súmula 231 do STJ. Terceira fase: ausentes causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena, por ser o réu primário e não se dedicar integralmente às atividades criminosas. Mas o patamar não será pelo máximo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela natureza nefasta do entorpecente apreendido, quantidade elevada, e também porque estava inserido num contexto organizado de venda de drogas, cumprindo ordens de um superior nesta cadeia odiosa, com horários de turno para cumprir, o que revela ajuste e combinação prévia. Neste cenário, diminuo a pena de metade, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão, e 250 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível, considerando a primariedade do acusado e a quantidade de pena aplicada, fixar o regime de pena intermediário.

Por ser o réu primário, de bons antecedentes, ter família constituída e residência fixa, e comprovando que não possui envolvimento com atividades criminosas, nem antes nem depois dos fatos, entendo que é o caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por lhe ser socialmente recomendável. Ao analisar o HC n. 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012.

Trata-se de rapaz jovem, que já trabalhou em vários locais, conforme as declarações nos autos (fls. 73/75), e mesmo não havendo prova do trabalho lícito, já que a carteira profissional está bem branco (fls. 63), já demonstrou que tem condições de se ressocializar se cumprir a pena restritiva, sendo-lhe socialmente recomendável. E uma vez que preenche os requisitos previstos no artigo 44 e parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos dos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal.

A pena de prestação pecuniária será cumprida mediante o pagamento do valor de um salário mínimo à entidade com destinação social, devidamente identificada pelo juízo da execução penal.

A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser executada durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade e será individualizada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.

No caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito, determino a conversão na pena privativa de liberdade acima fixada, nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, dada a substituição da pena por restritivas de direito, não se justificando, assim, a custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 250 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade fica substituída pelas penas restritivas de direito, nos exatos termos do acima fixados.

Expeça-se alvará de soltura.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois proveito do crime em apreço (fls. 40).

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação ds réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Drogas.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA